

1502456-87.2019.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... da condição de usuário.

É certo que, se é fato que o tráfico de drogas ilícitas banalizou-se, a ponto de propiciar a qualquer pessoa, mesmo que de renda mensal mínima a possibilidade de ganhar dinheiro com o tráfico, não é em razão disso que a conduta típica e antijurídica venha a ser menos perniciosa para a sociedade, posto que, como é cediço, o crime de tráfico, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502456-87.2019.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

CF, CF, BO, CF, BO, IP-Flagr. - 2250540/2019 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 7098062

- DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 5076/19/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2250540 -

1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 5076/19/942 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 2250540/2019 -

1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO MARQUES

Juíza de Direito: Dra. LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Cuida-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de Diego Marques, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Consta da denúncia que, no dia 28 de agosto de 2019, por volta das 11h30, na Rua Doutor Luís Henrique Geovanete, nº 694, Jardim Florence, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, o réu, trazia consigo, para inequívocos fins de entrega ao consumo de terceiros, 04 (quatro) invólucros contendo maconha (peso líquido 8,9g) e 71 (setenta e um) eppendorfs de cocaína (peso líquido 41,1g), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além do mais, o réu portava a quantia de R\$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais) em trocado.

Auto de prisão em flagrante (pág. 05); boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 10/12); auto de exibição e apreensão (págs. 13/14); laudo de constatação preliminar (págs. 16/18) e definitivo (págs. 53/55).

Por decisão datada de 31 de outubro de 2019 (págs. 66/67), foi determinada a notificação do acusado, sendo apresentada defesa preliminar por meio da Defensoria Pública (págs. 77/78). Não sendo o caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 14 de novembro de 2019 (págs. 79/80) e o réu devidamente citado (pág. 73).

Em audiência realizada aos 10 de março de 2020 (págs. 115/116), a representante do Ministério Público propôs ao acusado, tendo em vista preenchidos os requisitos previstos em lei, acordo de não persecução penal, o que fora aceito.

Por despacho datado de 11 de fevereiro de 2022 (págs. 144/146), ante a rescisão do acordo de não persecução penal pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e, após, foi o réu interrogado.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos moldes da denúncia.

A defesa pleiteou pela desclassificação para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06. Em caso de condenação, requereu a aplicação do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos carreados aos autos, o pedido inicial é procedente.

A materialidade de delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência de autoria conhecida, auto de exibição/apreensão, bem como pelos laudos periciais.

Do mesmo modo, a autoria restou incontestada ante toda a prova oral colhida nos autos sob o crivo do contraditório e direito à ampla defesa.

Vejamos.

A testemunha Nicacio dos Reis Silva, guarda municipal, em sede administrativa, informou que estava em patrulhamento na Rua Doutor Luis Henrique Geovanete, na altura do numeral 694, notório ponto de tráfico e uso de drogas, momento em que se deparou com um indivíduo que esboçava uma atitude suspeita, em aparente traficância. Ao perceber a aproximação da equipe, o acusado correu pela viela contígua e jogou ao solo uma sacola plástica. O réu foi acompanhado e detido. Em revista pessoal, foi possível localizar no bolso do acusado 01 (um) eppendorf de substância análoga à cocaína e em uma de suas mãos a quantia de R\$ 5,00 (cinco reais). A sacola plástica descartada por Diego foi recuperada e em seu interior foi possível encontrar mais R\$ 179,00 (cento e setenta e nove reais), 04 (quatro) porções de erva análoga à maconha e 70 (setenta) eppendorfs de substância análoga à cocaína. Os eppendorfs eram exatamente iguais aos que foram encontrados no bolso do acusado. Diego afirmou ser usuário e negou a posse das drogas encontradas na sacola.

Em juízo, disse que estavam em patrulhamento e se depararam com o acusado na entrada de uma viela. Ao visualizar a viatura, o acusado tentou correr e arremessou uma sacola. Com o réu havia um pino de droga e uma cédula de R\$ 5,00 (cinco reais). Na sacola dispensada havia maconha e cocaína, além de R\$ 170,00 (cento e setenta reais). O acusado assumiu informalmente a prática do tráfico de drogas para tentar reverter a dificuldade econômica.

Em seguida, o guarda municipal Sidney Vasconcelos Mello, em sede administrativa, apresentou versão dos fatos em consonância e harmonia com o narrado por seu colega de farda.

Em juízo, disse que estavam em patrulhamento na região do Jardim Florence, conhecido pelo comércio de drogas. Em dado momento, visualizaram o acusado se evadindo por uma viela. No caminho, ele jogou ao solo um saco plástico, que continha cocaína e maconha, além de quantia em dinheiro. A princípio, o réu negou o crime, porém em seguida, confirmou que havia começado a traficar drogas, pois estava passando por necessidade financeira.

O acusado Diego Marques, em sede administrativa, relatou que tem 21 (vinte e um) anos, faz "bico" em um lava rápido e ganha aproximadamente R\$ 1.000,00 (mil reais) por mês. Sobre os fatos alegados, informou que foi ao local com o intuito de comprar drogas. Esclareceu que comprou 01 (um) "pino" de cocaína. Ao ser abordado,

informou que iria comprar maconha pelo valor de R\$ 5,00 (cinco reais). Alegou não ter corrido dos guardas municipais e nem ter jogado uma sacola plástica, desconhecendo, portanto, a origem das drogas que foram apresentadas na delegacia. Por fim, disse que não conhecia os guardas municipais responsáveis pela prisão. Em juízo, negou o crime. Disse que estava no local para adquirir drogas. Que o rapaz que estava com a droga correu para o fundo da viela. Por fim, aduziu que trazia somente um pino de cocaína para consumo próprio. Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, ficou devidamente caracterizado o delito imputado ao réu.

Como se vê, o acusado trazia consigo, para inequívocos fins de entrega ao consumo de terceiros, 04 (quatro) invólucros contendo maconha (peso líquido 8,9g) e 71 (setenta e um) eppendorfs de cocaína (peso líquido 41,1g), substâncias essas capazes de causarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Importante salientar que a conduta do acusado se amolda perfeitamente ao tipo penal supracitado.

Para caracterizar o delito, basta que um dos verbos descritos no tipo se concretize, não sendo necessário que o infrator seja surpreendido no ato de mercancia, visto que se trata de crime de perigo abstrato.

Oportunamente, cumpre destacar que os guardas municipais reconheceram o acusado com sendo o autor do delito.

Ouvidos sob o crivo do contraditório foram uníssonos, coerentes e convincentes, descrevendo em harmonia e com riqueza de detalhes toda a abordagem que culminou na prisão do réu e na apreensão de todo o material em seu poder. Destarte, inexistente qualquer motivo que leve esta magistrada a crer que as narrativas foram fantasiosas ou inverídicas.

Ainda, consoante à prisão em flagrante realizada por guarda municipal, insta salientar que este constitui em ato legal, em prol da segurança social, ou seja, não há o que se falar em proibição ao guarda municipal em proceder à prisão. Nesse sentido, há o entendimento: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. ART. 301 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (art. 144, 8º, da CF), constitui ato legal, em proteção à segurança social. 2. Se a qualquer do povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há falar em proibição ao guarda municipal de proceder à prisão. 3. Eventual irregularidade praticada na fase pré-processual não tem o condão de inquinar de nulidade a ação penal, se observadas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, restando, portanto, legítima a sentença condenatória. 4. Ordem denegada. (HC 129932/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 01/02/2010).

São eles agentes do Estado, incumbidos a reprimir a criminalidade. Quando prestam depoimentos coerentes e seguros, inexistindo qualquer motivo para levar a crer que as narrativas foram inverídicas, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto condenatório.

Ademais, é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos dos agentes públicos de segurança não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva.

Por sua vez, em juízo, o acusado não apresentou qualquer versão que pudesse abalar os elementos amealhados da instrução criminal, ou eximi-lo de sua responsabilidade. Inclusive, há que se ressaltar que o réu confessou o delito na audiência de proposta de acordo de não persecução, oportunidade em que estava devidamente acompanhado pela Defensoria Pública, não tendo em momento algum, alegado a condição

de usuário de drogas. A confissão em acordo de não persecução penal é perfeitamente possível e válida para convencimento do juízo.

Importante destacar que a confissão prestada para fins do acordo coincide com os termos da confissão informada ao réu para o Guarda Municipal, ou seja, que passava por dificuldades financeiras e por essa razão estava praticando o tráfico ilícito de entorpecentes.

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

Ademais, o modo do acondicionamento da droga apreendida caracteriza de igual forma, a prática da mercancia, visto que as porções estavam prontas para serem distribuídas para comercializar.

Ora, é forçoso reconhecer que a conduta do acusado caracteriza o delito de tráfico de drogas, sendo imprescindível que o agente seja surpreendido praticando atos de comércio, por não ser a mercancia a única conduta existente no tipo penal mencionado no artigo 33 da Lei de Tóxicos.

As substâncias entorpecentes descritas na peça inaugural foram confirmadas pelo laudo de constatação preliminar e pelo laudo pericial definitivo (págs. 16/18 e 53/55, respectivamente), atestando seus efeitos e sua periculosidade, sendo detectadas, de fato, a presença de maconha e cocaína.

Ademais, as circunstâncias da prisão, o local conhecido como ponto de venda de drogas, natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos (cocaína e maconha), além da apreensão de quantia em dinheiro, cuja origem lícita não foi comprovada, impossibilitam a desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal.

Ainda que o acusado negue a propriedade das substâncias entorpecentes localizadas na sacola, fato é que se trata de prática usual nos delitos dessa natureza, com fulcro a se evitar a penalização estabelecida em lei, em caso de eventual abordagem, com alegação da condição de usuário.

É certo que, se é fato que o tráfico de drogas ilícitas banalizou-se, a ponto de propiciar a qualquer pessoa, mesmo que de renda mensal mínima a possibilidade de ganhar dinheiro com o tráfico, não é em razão disso que a conduta típica e antijurídica venha a ser menos perniciosa para a sociedade, posto que, como é cediço, o crime de tráfico, cujo bem jurídico é a saúde pública, dá causa, inegavelmente, a inúmeros outros ilícitos penais que são perpetrados em razão das drogas ou para propiciar a aquisição delas.

Para configuração do crime de tráfico de drogas, não se faz necessário que o infrator seja surpreendido no ato de mercancia, visto tratar-se de crime de perigo abstrato. A propósito: "... Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização ..." (RT 714/357). "... Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido ..." (RT 729/542).

Data vênua à combativa defesa, a condenação é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atenta aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por inexistirem circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Na segunda fase, verifica a atenuante da confissão espontânea quando da realização da audiência para proposta de acordo de não persecução penal, mas tendo em vista que a pena não pode ir além do mínimo legal, mantenho-a em seu patamar mínimo.

Na terceira fase, para a redução da pena, é necessário que o réu seja primário, tenha bons antecedentes, comprove que não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Contudo, o §4º do artigo 33, tem sua referência justamente no caráter isolado da conduta realizada, pressupondo mesmo não disponha

o réu no seu passado sinais de indicativos de que esteja fazendo do crime um meio de vida, atuando com profissionalismo.

Deve o julgador, neste caso, sopesar a quantidade de droga, variedades destas, bem como a análise do impulso, do fator determinante da conduta objetivamente tratada, que lhe permita concluir tratar-se mesmo de caso de um criminoso meramente ocasional, para que possa, não apenas determinar a gradação da redução da pena, como até mesmo o total afastamento da causa de redução.

Em relação ao réu, considerando os novos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência e o quanto determinado pelo STJ, de rigor reconhecer que as condições fáticas não permitem concluir que ele se dedique profissionalmente ao tráfico; além disso, a quantidade e variedade não é expressiva de modo a inviabilizar o benefício em questão. Assim, sendo o caso de aplicação do benefício no percentual de 2/3 (dois terços), resultando a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Sobre a possibilidade de utilizar a quantidade e diversidade de drogas como critério para diminuição da pena já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ARTIGO 33, PARÁGRAFO 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. ORDEM DENEGADA. 1. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida em poder da paciente justificam a aplicação do benefício previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, no piso mínimo (um sexto). 2. As instâncias inferiores decidiram em consonância com a jurisprudência desta e. Corte Superior, não caracterizada a coação ilegal descrita na inicial. 3. Ordem denegada. (STJ, HC 150407)

Por sua vez, oportuno ressaltar que não é inconstitucional a referida sanção pecuniária, a dar azo à aplicação desta pena nos termos do artigo 49 do Código Penal. Se o legislador optou por punir mais rigorosamente o crime de tráfico de drogas, em virtude de suas consequências nefastas à sociedade, justamente para desestimular a escolha desta atividade como meio de subsistência ou de enriquecimento - o que não viola qualquer princípio constitucional - cabe ao julgador aplicar a sanção pecuniária dentro dos limites legalmente estabelecidos, sendo certo que, nos termos do artigo 43 da Lei 11.343/06, o valor de cada dia-multa deve ser atribuído de acordo com a capacidade econômica do agente.

Nesse sentido: APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de desclassificação da conduta para a do artigo 28 da Lei de Drogas - Redutor de pena já beneficemente aplicado, em fração intermediária - Penas e regime prisional fixados com critério - Manutenção da pena de multa imposta, afastada a alegação de inconstitucionalidade - Negado provimento ao recurso. (TJ/SP - Apelação n.º 0014590-34.2014.8.26.0602/ SP, Rel. Des. Ricardo Sale Júnior, julgado em 30/07/2015, 15ª Câmara de Direito Criminal, publicado em 02/08/2015).

Ante o exposto julgo PROCEDENTE o pedido inicial a fim de CONDENAR o acusado DIEGO MARQUES ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

O dia-multa valerá o mínimo legal.

Determino regime semiaberto para início do cumprimento de pena, adotando como posicionamento a fundamentação exarada no V.Acórdão 2018.000245841, sendo relator o sempre culto Desembargador Nelson Fonseca Júnior;"... a teor a despeito da extensão das penas corporais aplicadas, não é caso de se manter o regime inicial aberto; quer em razão da gravidade do delito e da natureza de um dos entorpecentes apreendidos, quer em razão de o regime inicial aberto não se mostrar suficiente à prevenção e à repressão da infração penal perpetrada pelo réu (cf. artigo 33, § 3º, do Código Penal), além de não garantir o cumprimento das penas substitutivas impostas."

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e a frequência a curso ou tratamento pelo período de cumprimento de pena em locais a serem indicados pelo Juízo da Execução.

O réu poderá recorrer em liberdade, visto que permaneceu solto durante instrução do processo e por inexistem circunstâncias que ensejam mudança de medida.

Declaro o perdimento dos valores apreendidos em favor da União.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

LISSANDRA REIS CECCON

JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA